

1501764-37.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Na hipótese, a redutora do tráfico privilegiado não foi afastada somente em razão da quantidade e da natureza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501764-37.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501764-37.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262844/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 27666843 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2262844 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA BEATRIZ FERNANDES RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

ANA BEATRIZ FERNANDES RODRIGUES e RAFAEL VINICIUS BATISTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em concurso material com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a denúncia, no dia 26 de setembro de 2022, pela manhã, no endereço indicado na inicial, os denunciados traziam consigo drogas, sem autorização legal, para fins de tráfico.

Nos moldes da inicial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados

corromperam menor de dezoito anos de idade, CAUÃ MARTINS ANANIAS, com ele praticando infração penal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

DECIDO.

No mérito, cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelas fotografias acostadas (fls. 53), pelo laudo toxicológico (fls. 145/147), pelo laudo pericial no manuscrito com a aparente contabilidade do tráfico de drogas (fls. 142/144) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal dos réus, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que a denunciada negou os fatos, alegando, na fase judicial, tinha ido comprar drogas, oportunidade em que a polícia acabou por pegar a todos, sendo certo que é apenas usuária de drogas.

Contudo, suas alegações não encontram amparo na prova dos autos, eis que a prova oral colhida foi enfática em confirmar, sem sombras de dúvidas, o desenrolar fático apontado na denúncia.

Nesse sentido, o guarda municipal ANTONIO EDSON, na fase judicial, disse que estava em patrulhamento de rotina, de modo que acabou por se deparar com três indivíduos, que mostraram nervosismo e traziam consigo dinheiro trocado.

O guarda municipal disse que a denunciado trazia duas porções de cocaína, sendo certo que o denunciado e um menor de idade confessaram os fatos, afirmando que estavam traficando desde a noite anterior.

O guarda municipal afirmou que os indivíduos acabaram por indicar a denunciado como traficante de drogas também, descrevendo que ela atuava para o tráfico de desde a noite anterior.

O guarda municipal esclareceu, por fim, que, ao lado dos acusados, encontrou grande quantidade de drogas, mais especificamente em uma construção abandonada, sendo certo que não havia ninguém na rua.

Da mesma forma, foram as declarações do guarda municipal HUDSON, que, na fase judicial, confirmou a diligência e a abordagem aos denunciados, acrescentando que encontrou dinheiro com o denunciado e um menor de idade e, ainda, drogas e dinheiro com a acusada, tendo dito que todos confessaram o crime.

Na fase investigativa, os guardas municipais trouxeram versão idêntica sobre a dinâmica dos fatos (fls. 26/28).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos agentes públicos, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de

atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os guardas municipais tivessem trazido consigo drogas, prontas para serem comercializadas, mais dinheiro e um folha com anotações sobre a contabilidade do tráfico com o único propósito de forjar um ato de flagrante.

Não havendo nenhuma prova concreta que esteja a apontar que a diligência foi forjada, na medida em que não foi produzida nenhuma prova no sentido de, efetivamente, trazer contradições na versão dos agentes públicos.

Muito pelo contrário, a esse respeito, o denunciado RAFAEL confessou, na fase judicial, os fatos, dizendo que era responsável pelo dinheiro e o menor com “o pacote.”

O acusado afirmou, ainda, que a denunciada ANA BEATRIZ ficou no período do dia, tendo passado para o menor no período da noite, esclarecendo, ainda, que atuava para o tráfico fazia dois ou três dias.

Fechando o conjunto de provas, amplamente em desfavor dos réus e no sentido de atestar a validade do flagrante realizado, não se pode deixar de levar em consideração que o exame de corpo de delito não apontou qualquer lesão de interesse médico legal (fls. 89/90).

Em arremate, mister salientar que não há qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso dos autos, porquanto se tratou de situação de flagrante delito, que se revela cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

De fato, dispõe o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos.

A atribuição da guarda municipal insere-se nesse contexto, não só para fins de patrulhamento preventivo, como também para o uso progressivo da força, conforme disposto no artigo 3º, incisos III e V, da Lei Federal nº 13.022/2014, cabendo-lhe também “colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração” nos termos previstos no artigo 5º, IV e XIV, da citada legislação.

Em acréscimo, cabe destacar que não era necessária qualquer investigação prévia por parte dos agentes municipais, que estavam realizando ronda por local notoriamente conhecido pelo comércio de drogas, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita.

No mais, a revista pessoal está expressamente autorizada nos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial.

Na hipótese vertente, como já destacado, os agentes públicos estavam em local conhecido pela mercancia de entorpecentes e os denunciados apresentaram atitude manifestamente suspeita, justificando a atuação da Guarda Municipal, cabendo acrescentar que, ao final, a percepção dos guardas municipais mostrou-se absolutamente correta, eis que o réu RAFAEL confessou o crime.

Seguindo essa linha de entendimento, confira-se o seguinte julgado da 5ª Turma do

Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PELA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE LEGITIMAM A AUTUAÇÃO DA REFERIDA ENTIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Inicialmente, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifico tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, uma vez que tal pretensão não foi feita na inicial do writ, o que não é admitido pela jurisprudência. Ademais, ainda que assim não fosse, a reincidência do agravante obsta a concessão da benesse, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.

III - No que se refere à preliminar de nulidade pela atuação da guarda municipal, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a referida alegação que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal que, embora ressalte ser descabida a realização de investigações de práticas de ilícitos, disso não se desume a possibilidade de, mediante notícia de crime, proceder a diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "os Guardas Municipais, assim como qualquer outra pessoa do povo, ao contrário do entendido externado pela nobre Defesa, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito" (fl. 88), não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. Precedentes.

IV - Outrossim, descabida a alegação de que a basilar foi aumentada de forma inidônea, haja vista que a sentença condenatória levou em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, tratando-se de "04 porções de maconha, com peso líquido de 0,74g; 50 porções de maconha, com peso líquido de 105,98g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 11,93g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g; e 31 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 5,02g" (fl. 46), aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tudo de acordo com o entendimento deste Tribunal. Precedentes.

V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 748.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)."

Nesse panorama, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte ilegal de entorpecentes.

É que o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas pressupõe a vontade livre e consciente de perpetrar qualquer dos verbos do tipo penal, acrescida do elemento subjetivo do injusto, ou seja, do dolo específico de manter em depósito drogas para consumo próprio.

No caso em exame, as peculiaridades acima mencionadas, somadas à forma pela qual as drogas foram apreendidas, tendo havido apreensão de folha com anotação relacionada à contabilidade do tráfico de drogas, sem desconsiderar que o local é ponto de

venda de drogas, não estão a evidenciar nesse sentido.

Ao contrário, todas as provas produzidas revelam a atividade material descrita no tipo penal, no mínimo, consistente em trazer consigo drogas para entregar a consumo.

Em suma, a negativa da denunciada, desacompanhada de outras provas, acaba por ficar absolutamente isoladas diante do contexto probatório, sendo que a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, com a ressalva que o crime de corrupção de menores imputado, em função do princípio da especialidade, integrará a causa de aumento previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

A esse respeito, passo a indicar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.622.781/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016.

Assim, passo a dosar as penas:

DO RÉU ANA BETRIZ FERNANDES RODRIGUES;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, as peculiaridades do caso, especialmente o fato de o local ser conhecido ponto de venda de drogas, como afirmaram os agentes públicos, mais a quantidade e diversidade das drogas (fls. 20/21 – 217 porções de cocaína, 53 porções de maconha e 63 pedras de crack), sem desconsiderar a existência de apreensão de folha com a contabilidade do tráfico (fls. 144), fazem concluir que se dedica a atividades criminosas, não se tratando de criminosa não habitual.

A respeito da possibilidade de utilização das circunstâncias da prisão, principalmente quando relacionada com identificação de se tratar o local de ponto de venda de drogas, para este fim, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA ORIGEM. CORRETA A REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art.

59, do Estatuto Repressivo, a natureza, a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

- No caso, a fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base era idônea. De fato, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 184,2g de maconha e 85,8g de cocaína - desbordavam do ordinário do tipo e autorizavam algum quantum de incremento punitivo. Porém, não no patamar aplicado, na origem, que fugia à fração prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido, sem, contudo, explicitar qualquer razão especial que autorizasse o apenamento mais rígido, além do insito à circunstância judicial referida. Por isso, foi a ordem concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base do ora agravante para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Na hipótese, a redutora do tráfico privilegiado não foi afastada somente em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, porquanto as instâncias de origem consignaram também que o ora agravante se dedicava ao tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia militar que ele estaria traficando drogas (o que foi confirmado por seus vizinhos) -, as quais realmente sugerem que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, o apenado jus à aplicação da referida minorante. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

- O regime prisional permanece na modalidade fechada, considerando o quantum da reprimenda final (superior a 4 anos de reclusão e não superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

- Não há ilegalidade flagrante na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)."

A este respeito, indicamos o seguinte julgado da 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021.

Por fim, reforçando esse entendimento, não se pode desconsiderar que a denunciada estava associada com o menor de idade CAUÃ na venda dos entorpecentes, circunstância que potencializa a sua conduta, afastando-se qualquer dúvida de que se trata de traficante profissional.

Em suma, sob todos os ângulos analisados, possível concluir que não faz jus à causa de diminuição.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de considerar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, em função do envolvimento do adolescente CAUÃ, a fim de evitar bis in idem, eis que a circunstância foi utilizada para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente,

a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
 2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
 4. Agravo regimental não provido.
- (AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).”

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

A ré poderá apelar em liberdade.

DO RÉU RAFAEL VINICIUS BATISTA;

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, as peculiaridades do caso, especialmente o fato de o local ser conhecido ponto de venda de drogas, como afirmaram os agentes públicos, mais a quantidade e diversidade das drogas (fls. 20/21 - 217 porções de cocaína, 53 porções de maconha e 63 pedras de crack), sem desconsiderar a existência de apreensão de folha com a contabilidade do tráfico (fls. 144), fazem concluir que se dedica a atividades criminosas, não se tratando de criminosa não habitual.

A respeito da possibilidade de utilização das circunstâncias da prisão, principalmente quando relacionada com identificação de se tratar o local de ponto de venda de drogas, para este fim, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA ORIGEM. CORRETA A REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO

LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art.

59, do Estatuto Repressivo, a natureza, a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

- No caso, a fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base era idônea. De fato, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 184,2g de maconha e 85,8g de cocaína - desbordavam do ordinário do tipo e autorizavam algum quantum de incremento punitivo. Porém, não no patamar aplicado, na origem, que fugia à fração prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido, sem, contudo, explicitar qualquer razão especial que autorizasse o apenamento mais rígido, além do insito à circunstância judicial referida. Por isso, foi a ordem concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base do ora agravante para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Na hipótese, a redutora do tráfico privilegiado não foi afastada somente em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, porquanto as instâncias de origem consignaram também que o ora agravante se dedicava ao tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia militar que ele estaria traficando drogas (o que foi confirmado por seus vizinhos) -, as quais realmente sugerem que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, o apenado jus à aplicação da referida minorante. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

- O regime prisional permanece na modalidade fechada, considerando o quantum da reprimenda final (superior a 4 anos de reclusão e não superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

- Não há ilegalidade flagrante na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)."

A este respeito, indicamos o seguinte julgado da 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021.

Por fim, reforçando esse entendimento, não se pode desconsiderar que o denunciado estava associado com o menor de idade CAUÃ na venda dos entorpecentes, circunstância que potencializa a sua conduta, afastando-se qualquer dúvida de que se trata de traficante profissional.

Em suma, sob todos os ângulos analisados, possível concluir que não faz jus à causa de diminuição.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de considerar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, em função do envolvimento do adolescente CAUÃ, a fim de evitar bis in idem, eis que a circunstância foi utilizada para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).”

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva (fls. 66/69), que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão não impugnada pela Defesa.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONDENO ANA BETRIZ FERNANDES RODRIGUES e RAFAEL VINICIUS BATISTA, qualificados nos autos, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incursos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06.

ABSOLVO-OS da imputação relacionada ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA